

1500791-83.2020.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... o réu confessou prática de tráfico e indicou o local onde havia mais drogas, resultando no encontro de 92 pinos de cocaína.

Na delegacia de polícia, o réu confessou o tráfico de drogas (fls. 4)

Afirma a inicial que a finalidade de tráfico se demonstra pela quantidade de drogas apreendidas, modo de embalo, tentativa de se livrar da prova da materialidade e pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500791-83.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500791-83.2020.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR TOLEDO DA LUZ

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Julio Cesar Toledo da Luz foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 15h05min, na Rua Capitão Adolfo Monteiro, número 315, Aeroporto, nesta cidade de Taubaté, para fins de tráfico, trazia consigo e tinha em depósito drogas, que causam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais em patrulhamento de rotina avistaram o réu, o qual, ao avistar a viatura policial, saiu correndo, oportunidade em que dispensou uma sacola plástica, contendo 36 porções de Cannabis Sativa L, droga popularmente como maconha, mas foi detido.

Ao ser questionado, o réu confessou prática de tráfico e indicou o local onde havia mais drogas, resultando no encontro de 92 pinos de cocaína.

Na delegacia de polícia, o réu confessou o tráfico de drogas (fls. 4)

Afirma a inicial que a finalidade de tráfico se demonstra pela quantidade de drogas apreendidas, modo de embalo, tentativa de se livrar da prova da materialidade e pela tentativa de fuga.

Sustenta, ainda, que nas duas ocasiões em que foi detido por tráfico de drogas, o réu praticava a venda dos entorpecentes nas imediações de uma mesma região, há 1 km de duas escolas.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, caput, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi recebida às fls. 130/132.

Citado (fls. 146), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 159/161.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidos os policiais militares Fabricio Mont Alverne e Thalles Daniel de Aquino Oliveira. Em seguida procedeu-se ao interrogatório do réu, oportunidade em que foi postulada e deferida a instauração de incidente de insanidade mental.

Com o laudo nos autos, vieram os memoriais.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Manifestou que a negativa de autoria diverge do conjunto probatório, sendo inútil tentativa de livrar-se da grave imputação penal. Ressaltou que as circunstâncias da abordagem, a ausência de outras pessoas no local, a localização de droga da mesma natureza da encontrada na posse do réu, a diminuta distância entre ele e o esconderijo dos entorpecentes e a confissão informal são elementos suficientes para comprovar a prática do crime. Afirmou que a alegação de problemas mentais para justificar o uso da maconha como medicação também não prospera considerando o laudo pericial encartado aos autos o qual concluiu pela capacidade de entendimento. Afirmou que os depoimentos policiais foram coerentes e harmônicos, motivo pelo qual merecem credibilidade e servem como fator determinante para a formação de convicção do julgador. No caso concreto, pontuou inexistirem justificativas plausíveis para desmerecer as versões apresentadas em desfavor do réu. Enfatizou, ainda, ser plenamente possível a cumulação da traficância com o uso de drogas, sendo muito comum ao traficante utilizar-se de parte da droga para uso próprio, entretanto, deve prevalecer o crime mais grave. Acrescentou que a quantidade de entorpecente apreendido, bem como a forma de acondicionamento, são fortes indicativos de que se destinava à venda, principalmente diante das circunstâncias de modo e lugar em que o crime ocorreu. Na dosimetria, na primeira fase, vislumbrou a presença de maus antecedentes por condenação atingida pelo período depurador, pleiteando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, há a atenuante da confissão, feita na fase policial. Na terceira fase de dosimetria da pena, afirmou ser impossível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, por haver indícios de dedicação às atividades criminosas e reincidência pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, cabível a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas por estar comprovada a proximidade de escolas. Para o regime de cumprimento, solicitou que seja fixado o fechado.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, sustentando que a palavra dos policiais não é suficiente para embasar a condenação. Afirmou não existirem provas judiciais, isto é, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que apontem a autoria delitiva, a fim de ensejar um juízo condenatório. Pleiteou que

seja aplicada a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse para uso próprio.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, caput, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de parcial acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 22/24, auto de exibição e apreensão de fls. 26, laudo pericial de constatação provisória de fls. 27/31, laudo definitivo de fls. 153/155 e laudo do incidente de insanidade (fls. 357/360).

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico.

A testemunha Thalles Daniel de Aquino Oliveira, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento no local, conhecido pelo tráfico de drogas, em razão de frequentes denúncias dos moradores. Na ocasião, visualizaram um indivíduo, o qual tentou se evadir ao notar a presença dos policiais. Ao se aproximarem o réu jogou uma sacola ao chão. Em abordagem nada de ilícito foi encontrado. Na sacola recuperada localizaram porções de maconha. Ao ser indagado o réu confessou informalmente o tráfico e indicou outro ponto de armazenamento próximo a ele, em um buraco no muro. Nesse segundo momento, encontraram uma sacola contendo eppendorfs com cocaína. Alegou que não conhecia o réu anteriormente. Garantiu que o réu estava sozinho e não resistiu à abordagem.

A testemunha Fabricio Mont Alverne, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao se aproximarem ele tentou fuga e arremessou uma sacola. Nessa sacola encontraram porções de maconha. Em seguida o réu indicou a localização de outra sacola, escondida nas proximidades, a qual continha pinos com cocaína. Afirmou que o réu não aparentava alteração ou confusão mental.

O réu Júlio Cesar Toledo da Luz, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Informou que estava no local apenas para comprar maconha, para seu consumo. Na ocasião da abordagem, estava fazendo o consumo do entorpecente e possuía mais uma porção de maconha consigo. Negou a posse de uma sacola. Explicou que havia acabado de comprar a droga que estava enterrada, sendo que assim o fez para poder usá-la em outro momento. Mencionou ter doenças mentais e tomar remédios controlados, tal qual Tanvotril, para depressão. Antes da pandemia, fazia tratamento no CAPS. Deseja fazer novo tratamento. Disse trabalhar como vigia de carros. Usa drogas desde os 13 anos de idade e já passou por tratamento. Tem outra condenação por tráfico de drogas.

Bem provadas a autoria e a materialidade

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

"Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

...

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;"

Dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que se somam às provas produzidas sob o contraditório judicial, verifica-se que a conduta do réu se enquadra no verbo trazer consigo e guardar drogas, previsto no núcleo do tipo, assim, configurada a traficância.

Com efeito, os policiais ouvidos afirmaram que logo que o réu avistou a viatura dispensou uma sacola (que continha drogas em seu interior) e apontou, ainda, outro local onde escondia o restante das drogas.

Anoto que o fato de haver apenas o testemunho dos policiais, não basta para infirmar o teor dos depoimentos, ainda mais sem qualquer outro elemento de prova em sentido contrário.

Registro que os depoimentos prestados são coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalto que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos se reveste de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Além disso, quando ouvido na delegacia, o réu confessou que ali realizava o tráfico (fls. 4).

Assim, não há dúvida acerca dos fatos, que demandam a responsabilização do réu.

A alegação defensiva, tanto em autodefesa como em defesa técnica, de que a droga se destinava ao uso não encontra guarida nos elementos de prova existentes nos autos.

Primeiro porque o réu confessou na delegacia que estava no local a traficar.

Ademais, cabe dizer que a retratação posterior não invalida aquela realizada na delegacia de polícia.

Anoto que na oportunidade de seu primeiro interrogatório, os fatos estão vivos na memória e, muitas vezes em razão da surpresa e do curto espaço tempo decorrido entre o fato e a oitiva, a verdade vem à tona, sem que tenha tempo hábil para que o acusado formule teses defensivas, desviadas da sinceridade.

Nesse passo é que entendem os tribunais que a confissão vale por seu próprio teor, e não pelo lugar onde é prestada.

“Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do correu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua participação na empreitada, não tentando se eximir de sua responsabilidade”(TJSP, Apelação Criminal nº 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel.Des. Souza Nery, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/11/2012).

A propósito, cabe o registro que em seu interrogatório em juízo o réu afirmou que apenas usava e que trazia consigo uma bucha de maconha, alterando a versão dos fatos ocorridos, tentando induzir o Juízo em erro, unicamente para tentar se afastar da responsabilidade que é certa.

Ademais, a quantidade de droga com ele encontrada não demonstra que fosse para seu uso. Com efeito, foram 50g de maconha e 36 de cocaína o que, indubitavelmente, não se mostra compatível com o uso próprio.

No que toca à causa de aumento de pena, observo que não se aplica ao caso concreto.

Com efeito, a análise detida dos autos permite concluir que o réu não se encontrava nas proximidades das escolas, pois o local em que foi preso estava distante um quilômetro delas.

A ratio da lei é evitar que o tráfico se aproveite dos estudantes que ali estão vulneráveis o que, no caso, não resultou comprovado. O réu foi preso por volta de 15 horas, quando os estudantes ainda estão na escola. Além disso, como declinado, o réu não se encontrava nas proximidades da escola, mas distante aproximadamente um quilômetro.

Assim, não se verifica que sua atuação visasse aos estudantes.

Quanto à suspeita de que fosse o réu inimputável, o laudo de fls. 357/360 afirmou que é ele pessoa lúcida, consciente e orientada, não apresentando qualquer transtorno mental e, na época dos fatos, era plenamente capaz de determinar-se de acordo com a lei.

Vê-se, nesse contexto, que o réu era, por ocasião dos fatos, imputável e tinha plena consciência do ilícito perpetrado, não havendo excludente de ilicitude ou de culpabilidade que viesse em seu benefício.

A prova nos autos produzida, atenta ao contraditório e à ampla defesa, é segura e não deixa dúvida de que praticou a conduta descrita na denúncia, devendo responder pelo crime em questão.

Afirmada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, atendendo-se à disposição do artigo 68, do Código Penal, ao critério trifásico proposto por Nélson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social da agente.

A qualidade da droga a despeito de significativa não pesa em desfavor do réu.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta desclassificação. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa - que não é absoluta - demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não

há a correspondente obrigação de ignorar a verdade".

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo "A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu

interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demaís disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decísum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu

mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

Em outro processo que teve trâmite por esta Vara (1501572-71.2021), bem concluiu o Ilustre Desembargador Zorzi Rocha:

“A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, destacada a rubrica da personalidade desregrada do Réu o qual modificou a realidade dos fatos com o nítido intuito de minimizar os efeitos de sua conduta, dificultar a análise da prova e criar a ideia de irregularidade da conduta policial. Não se trata de mera mentira narrada em Juízo, mas da criação de realidade diversa (disse que era tatuador e tinha um estúdio de tatuagem), com a produção de prova testemunhal nesse sentido (a testemunha João Pedro disse em Juízo que foi tatuado pelo Réu, embora nunca tivesse visto seu estúdio/oficina). Destaque-se que o próprio Réu confirmou informalmente que produzia armas artesanais, fornecendo detalhes de como eram feitas a produção e a usinagem, sendo essa narrativa judicial conduta que realmente extrapolou os limites da autodefesa, podendo ser utilizada de forma regular e como aqui ocorreu para exasperação da pena-base.” (Apelação Criminal, j. em 26.5.2022).

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie.

O réu ostenta maus antecedentes pelo processo 11036-61.2010, desta 3.^a Vara Criminal de Taubaté.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Diante da personalidade negativa e dos maus antecedentes, elevo a pena mínima em 1/4 e fixo a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, além de 625 dias-multa.

Na segunda fase, vislumbro as circunstâncias atenuantes da confissão levada a efeito na delegacia, que demanda a atenuação da pena em 1/6, que passa a totalizar 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias-multa, não havendo circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da reprimenda não há causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo a pena definitivamente em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento será o fechado.

Trata-se de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado.

Nada obstante, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, reforçando a necessidade do regime mais rigoroso.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do delito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime, insuficiente seria sua aplicação, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Incabível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, da reincidência, bem como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Anoto, ainda, que a despeito da Resolução n 5, do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a conversão e o sursis não se fazem adequados à prevenção e repressão do crime em espécie, pois, como já se decidiu, "os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com reação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, 'os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente'" (TJSP, apelação 0026205.40.2008.8.26.0405).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Anoto que no decorrer do

processo esteve ele em liberdade, não se vislumbrando necessidade de alteração desse estado, prestigiando assim a presunção da inocência, pois ausentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar.

Como afirma Ricardo Schmitt, "como regra geral, temos que se o sentenciado se encontra solto, em liberdade plena no momento da sentença, tendo permanecido nesta situação durante a instrução processual, em princípio possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se existir algum motivo ponderoso à aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou, em último caso, de decretação de sua custódia preventiva" (Sentença Penal Condenatória, 8.^a ed., Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p. 443).

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, §2, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito por conta do período de prisão cautelar, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes – 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho parcialmente o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Julio Cesar Toledo da Luz à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA